

제62회 변리사 시험 상표법 해설

By. 한빛 상표법 강사진

안녕하세요.

한빛 상표법 강사진입니다.

제62회 변리사 2차 시험이 끝났습니다.

덥고 습한 날씨에 시험보시느라 모두 고생많이하셨습니다.

다들 후회없이 치열하게 시험 보셨기를 기원합니다.

올해 상표법 문제는 난이도는 매우 어려운 편이었습니다.

다만, 물어보는 점이 명확한 점, 수업에서 중요한 논점으로 다룬 부분이 다수 출제된 점을 고려하면 ‘물어보는 바에 명확히 답하는 것’ 만 잘하신 경우에도 고득점이 가능할 것으로 판단됩니다. 특히 1차 문제처럼 조문을 가지고 O/X를 가리는 문제가 출제된 점에서는 수험생 여러분들이 많이 당황하셨으리라고 예상됩니다. 모두 어려운 시험 치르시느라 고생하셨습니다.

변리사 2차 시험은 4가지 종목을 모두 잘해야하는 종합 스포츠, 종합 예술이라고 생각합니다. 모든 과목에서 후회 없는 준비기간과 후회 없는 시험을 치르셨기를 믿어 의심치 않으므로 여러분의 합격을 기원하겠습니다.

2025. 07. 20.

김세원, 천훈기, 정혜진 드림.

*본 해설 자료는 강사진이 작성한 견해에 불과하므로 이의신청의 근거가 될 수 없습니다.

대천읍은 충청남도 홍성군에 있는 읍으로서, 김 양식업이 번성하던 천수만과 연결되어 일제 강점기 시절부터 천수만 일대에서 생산, 제조, 가공된 김이 뱃길을 따라 모여 판매되는 다양한 김 유통시장이 크게 발달하였다. 이에 따라 대천읍은 일반 수요자들이 김의 생산지로 오인할 정도로, 김에 대한 명성을 얻었다.

그런데 1990년경부터 천수만 간척 사업이 시작되어 대천읍은 더 이상 뱃길로 바다에 연결되지 않았다. 이에 대천읍 일대 상인들은 지역상권이 쇠퇴하는 것을 막기 위하여 대천김영어조합법인(이하 ‘甲’)을 설립하고 2000년경부터 대천읍 일대 김 가공업체들이 ‘조미구이 김(도시락김)’을 가공 판매하기 시작하였으며, ‘대천김’ 축제를 개최하여 ‘조미구이 김’을 지역 특산물로 적극적으로 홍보하였고, 이로써 대천읍은 2017년경 ‘조미구이 김’의 높은 품질 등으로 일반 수요자에게 큰 명성을 얻게 되었다.

(1) 상표법상 ‘지리적 표시 단체표장’ 등록출원시 특허청에 제출해야 하는 서류를 설명하시오. (4점)

(2) 甲이 2018. 2. 1. 표장 “K-STAR 대천김”을 지정상품 제29류 “김, 조미 김, 구이 김”으로 특허청에 지리적 표시 단체표장 등록출원하였을 경우, 아래 주어진 사실관계를 고려하여 특허청의 심사 결과를 예상하고, 이 출원을 등록받기 위한 방안을 설명하시오. (14점)

지리적 표시 단체표장 등록출원 당시 사실관계

[甲의 정관에 포함된 조합원(통상사용권자) 명부]

주식회사 A (대천읍 소재, 김 가공업)

주식회사 B (대천읍 소재, 김 유통업)

개인기업 C (부천읍 소재, 김 가공업)

개인기업 D (대천읍 소재, 김 가공업)

개인기업 E (대천읍 소재, 김 가공업)

지리적 표시 단체표장 등록출원 당시 사실관계

- 甲은 특허청에 제출해야 하는 서류를 충실하게 제출하였음.
- 甲이 제출한 정관 및 정관의 부속서는 아래와 같음.
- 甲의 정관은 상표법 시행령 제3조(단체표장 사용에 관한 정관의 기재사항)를 만족함.

[甲의 정관]

(중략)

제49조 조합원은 ‘대천읍 내’에서 ‘조미구이 김’을 가공 또는 유통하는 사업자가
어야 한다.

제50조 (1) 조합원은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품의 품질 특성의 유지를 위한
‘자체관리기준’과 ‘유지관리방안’을 준수하여야 한다.

(2) 상표법에 의한 지리적 표시 단체표장을 사용할 수 있는 상품의 특정 품질, 명성
또는 그 밖의 특성과 연관된 대천읍 지역의 지리적 환경 요인, 지리적 표시 대상지역,
품질 등의 자체관리기준, 품질 등의 유지관리방안은 본 정관의 부속서에 기재된 바에
따른다.

(3) 제2항의 규정에 의한 정관의 부속서는 정관의 일부로 보며, 정관과 동일한 효력을
가진다.

[甲의 정관의 부속서]

(중략)

1. 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성 및 자체관리기준

(1) 원재료에 의한 품질 특성: ‘조미구이 김’은 타 상품과 달리 서해안이나 대천읍
근처 김 원초, 국내산 참깨로 직접 짠 참기름, 국내산 천일염을 사용하여 맛과 향이
매우 뛰어나다.

(2) 가공 공정에 의한 품질 특성: ‘조미구이 김’은 타 상품과 달리 염선된 김 원초
를 영하 18도 이하로 급냉 건조시킨 후 참기름을 앞뒤로 3회 바른 후 3회 구워 향이
풍부하고, 천일염을 2초 동안 2회 골고루 뿌려 맛이 좋으면서 나트륨 함량이 20~30%
낮다.

2. 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성의 유지관리방안

(1) 원재료에 대한 자체관리기준을 위반한 경우: 1차 위반시 3개월 표시 금지, 2차 위
반시 제명

(2) 가공 공정에 대한 자체관리기준을 위반한 경우 : 1차 위반시 시정명령, 2차 위반시
3개월 표시 금지, 3차 위반시 제명

(3) 甲이 지리적 표시 단체표장을 물음 (2)에 따른 조치에 따라 2019. 2. 1. 설정등록한
후, 권리를 침해하고 있는 乙에게 경고장을 발송하자, 乙은 甲의 지리적 표시 단체표장
에 대하여 2020. 2. 1. 특허심판원에 등록취소심판을 청구하였다. 아래 주어진 사실관계
를 고려하여 乙의 청구 이유를 예상하고, 특허심판원의 심결을 논하시오. (12점)

지리적 표시 단체표장 설정등록 이후 사실관계

사용자	주식회사 A	주식회사 B	개인기업 D	주식회사 E	주식회사 F
조합원 여부	O	O	O	X	O (등록 후 가입)
주소	대천읍	순천읍으로 이전	대천읍	대천읍	대천읍
사용표장	왕후 대천김	대천김	대천김	대천김	대천김
사용상품	김자반, 김밥김	조미구이 김	조미구이 김	조미구이 김	구운 감태
사용참기름	국내산 참기름	국내산 참기름	외국산 참기름	국내산 참기름	국내산 참기름
사용소금	국내산 천일염	국내산 천일염	정제염, 맛소금	국내산 천일염	국내산 천일염

- 일반 수요자는 주식회사 A의 상품에 대하여 ‘유명한 상품이라고 믿고 구매했어요’ 등의 상품평을 남김.
- 甲의 조합원 명부에는 실제 조합원인 ‘개인기업 E’ 대신 ‘주식회사 E’로 적혀 있었는데, 甲은 오히려 ‘주식회사 E’는 원래부터 자기 조합원이 아니라고 진술하였음.
- 甲은 특정 사용자에게 위와 같은 지리적 표시 단체표장의 사용을 중지할 것을 요구한 바가 없음.
- 모든 사용자는 甲의 등록번호를 사용상품에 표시하고, ‘전통과 명성을 이어온~’, ‘엄선된 원료로 만든~’ 등의 홍보 문구를 표시하고 있음.

<Comment.>

최근 중요 판례로 찍힌 광천김 판례 기반 문제입니다. 설문 (1),(2)는 당연한 지표단 법리를 출제한 점에서 기본기로 사안 포섭을 잘하시는 능력이 요구되는 문제였습니다. 다만, 문제 길이가 압도적이어서 수험장에서 매우 까다로웠을 것으로 보입니다. 조문에 근거하여 논리적인 답안을 전개하였다면 충분한 문제입니다.

[문제-1] “대천김 문제” (상표법은 이하 ‘法’ 이라 함)

I. 설문 (1)의 해결

1. 지리적 표시 및 지리적 표시 단체표장의 개념(★)

- (1) 法2조 1항 4호
- (2) 法2조 1항 6호

2. 설문의 해결 - 특허청에 제출해야하는 서류

- (1) 法36조 3항 및 法36조 5항
- (2) 결론
 - 1) 지리적 표시의 정의에 일치함을 증명하는 서류
 - 2) 지리적 표시 단체표장과 관련된 사항을 정한 정관

II. 설문(2)의 해결

1. 문제의 소재

2. 특허청의 심사결과

(1) 지리적 표시 정의규정 합치여부 (★)

1) 대천김 자체

‘대천김’ 자체는 ‘조미구이 김’의 생산, 판매지로 명성을 취득하였으므로 정의규정 만족함

2) 표장에 대한 심사

① 심사기준

지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 보호하는 것을 목적으로 하므로, 원칙적으로 지리적 표시만으로 구성된 표장 또는 지리적 표시와 상품명을 결합한 표장만을 지리적 표시의 정의에 합치하는 것으로 본다. 따라서, 표장의 구성에 있어서 해당 지리적 표시를 수식 또는 한정하거나 별도의 식별력을 가진 문자를 결합한 경우 정의규정에 합치하지 않는 것으로 본다.

② 이 출원의 경우

식별력이 있으며, 표장에서 높은 비중을 차지하는 ‘K-STAR’ 부분이 결합되어 있으므로 지리적 표시 단체표장의 표장으로 인정될 수 없음

3) 지정상품에 대한 심사

① 심사기준

지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 등록받을 수 있으므로 원칙적으로 지리적 표시의 정의에 합치됨을 입증하는 자료를 제출한 1개의 상품을 지정상품으로 하여 등록받을 수 있다. 다만, 원재료 상품 및 그 원재료 상품의 주원료가 되는 원료로 만든 복수의 가공품 등과 같이 매우 긴밀한 연관관계가 있고, 각각의 지정상품에 대하여 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증하는 서류가 제출되는 경우에는 2개 이상의 지정상품을 등록받을 수 있다.

② 이 출원의 경우

정관을 검토한 결과 ‘조미구이 김’에 대한 서류만 제출되었으므로 ‘김, 구이김’에 대하여 ‘대천김’은 지리적 표시 단체표장의 정의규정에 합치하지 아니함.

4) 소결

甲의 출원은 표장과 지정상품이 지리적 표시 정의규정에 합치하지 않으므로 法2조 1항 4호 및 6호의 거절이유가 존재함.

(2) 출원인 적격 만족여부

1) 法3조 2항

2) 소결

개인기업 C의 경우 부천읍에 소재한 자이므로 출원인 적격위반으로 法3조 2항 거절이유 존재함.

(3) 결론

지리적 표시 및 지리적 표시 단체표장의 정의규정(法2①4,6) 위반의 거절이유가 존재하고, 출원인 적격(法3②)의 위반의 거절이유가 존재하므로 특허청의 심사결과는 이 출원에 대하여 거절결정을 내릴 것으로 예상됨.

3. 甲이 이 출원을 등록받기 위한 방안 (★)

(1) 표장의 보정

1) 심사기준

지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 출원에 있어서 지리적 표시 부분을 제외한 표장의 나머지 부분을 삭제보정하는 내용의 상표보정은 법 제40조제2항에 의한 출원의 요지변경에 해당하지 않는 것으로 본다.

2) 소결

‘K-STAR’ 부분을 삭제하는 보정 수행과 해당 부분은 지리적 표시와 무관한 부분이라는 점을 주장하는 의견서 제출

(2) 지정상품 삭제보정

정의 규정에 합치하지 않는 ‘김, 구이김’ 삭제보정

(3) 수정정관 제출

1) 法제43조 제1항

2) 소결

수정정관을 제출함으로써 개인기업 C를 조합원에서 제외하여야 함.

4. 설문의 해결

(1) 甲의 출원은 정의규정 위반(法2①4,6) 및 출원인 적격 위반(法3②)으로 거절결정이 예상되나, 상표와 상품을 보정하고, 수정정관을 제출하는 것으로 등록 방안을 강구해야함.

(2) [보론] 다만, 표장 삭제보정이 표장에서 큰 비중을 차지하는 부분을 삭제하는 것으로 취급되거나, ‘K’ 부분으로 인하여 지리적 표시와 관련된 부분으로 인정되는 것을 방지 하기 위하여 보정된 내용으로 재출원을 하는 것도 방안임.

Ⅲ. 설문(3)의 해결

1. 문제의 소재

2. 乙의 청구이유

(1) 法119조 1항 2호

1) 의의 및 취지

2) 判例 - 품질오인의 염려 (★)

‘상품 자체의 오인과 산지의 오인도 포함한다.’

3) 소결

i) A는 김자반, 김밥김에 지리적 표시 단체표장을 사용하고 있는데, 일반 수요자는 상품평에서 품질 오인을 하고 있는 것으로 보임 ii) 또한, B는 순천읍에서 상품을 생산하고 있으며, iii) F는 구운감태에 지리적 표시 단체표장을 甲의 등록번호와 함께 홍보문구도 기재하여 사용하고 있으므로 法119조 1항 2호의 청구이유 주장 가능함.

(2) 法119조 1항 7호 가목

1) 의의 및 취지

2) 判例 - 정관의 위반한 경우 (★)

지리적 단체표장은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산, 제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장이다. 지리적 단체표장의 권리는 법인에게 귀속되지만 표장은 법인 뿐 아니라 소속 단체원도 사용할 수 있으므로 권리자인 법인에게는 소속 단체원들이 권리범위를 넘어 무단으로 사용하지 않도록 소속 단체원을 관리, 감독할 의무가 있고, 소속단체원들도 지리적 단체표장의 대상지역과 지정상품 및 상품을 제조하는 재료와 제조방식이 상세하게 기재된 정관의 규정을 준수해야 한다.

3) 소결

조합원 A 및 F는 정관에서 정한 상품이 아닌 상품을 사용하고, 조합원 B는 정관에서 정한 지역이 아닌 순천읍에서 생산된 상품에 지리적 표시 단체 표장을 사용하며, 조합원 D는 정관에서 정한 생산방법을 위반함. 그러나 甲은 사용 중지를 요청하지도 않아서 상당한 주의는 인정되지 않음. 따라서, 法119조 1항 7호 가목의 청구이유 주장가능

(3) 法119조 1항 7호 다목

1) 의의 및 취지

2) 判例

설문과 유사한 사안에서 ‘지리적 표시 단체표장권자 스스로도 개인기업만이 조합원이라고 주장하고 있어 주식회사가 조합원이 아니라는 점을 이미 알고 있었던 점에서 지리적표시 단체표장권자는 주식회사가 이 사건 단체등록상표를 무단으로 사용하지 못하도록 적절한 조치를 취했어야 할 것이다.’ 고 설시한 바 있음

3) 소결

주식회사 E는 조합원이 아니고, 甲도 이를 인지하고 있었음에도 고의로 적절한 조치를 취하지 않았으므로 法119조 1항 7호 다목의 취소사유가 존재.

(4) 法119조 1항 8호 가목

1) 의의 및 취지

2) 소결

F는 ‘구운 감태’를 생산하는 자로써 조합에 가입할 수 없는 자임에도 이 사건 지리적 표시 단체표장 등록 후 가입한 것이므로 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우에 해당하여 法119조 1항 8호 가목의 취소사유 존재.

3. 설문의 해결 - 특허 심판원의 심결

(1) 甲의 지리적 표시 단체표장에 대하여 乙은 法119조 1항 2호, 7호 가목, 7호 다목 및 8호 가목의 취소사유를 청구이유로 주장할 것으로 예상됨.

(2) 이 경우 모든 청구이유는 이유 있으므로 인용심결 될 것임.

甲은 2020. 2. 1. 설정등록한 상표 A의 상표권자이다. (지정상품: 제24류 수건, 타월 등)
乙은 수건을 주로 판매하는 사업자로서, 甲의 동의 없이 甲의 인감도장을 몰래 가져와서
A 상표권에 대한 양도증에 무단 날인한 뒤, 이를 2020. 5. 1. 특허청에 제출하여 乙 명의
로 상표권 이전등록을 완료하였다.

이후 乙은 상표 A를 표시한 수건을 200개는 일반 수요자에게 판매하였고, 200개는 주요
거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였으며, 200개는 판매 목적으로 소지하였다.

(1) 상표권 침해에 해당하는 경우 상표법상 벌칙 규정에 대하여 설명하십시오. (4점)

(2) 乙의 각 행위에 대하여 甲의 상표권 침해죄(상표법 제230조)가 성립하는지 여부를 논
하십시오. (10점)

(3) (별개 사안임) 한편 상표권자 甲은 A 상표권에 대하여 丙에게 사용기간을 ‘2021. 2.
1. ~ 2030. 2. 1.’ 및 사용지역을 ‘대한민국 전 지역’ 으로 하는 무상의 통상사용권을
2021. 2. 1. 유효하게 설정하였고, 丙은 이를 특허청에 등록하지 않았으며, 丁에게 사용기
간을 ‘2024. 2. 1. ~ 2030. 2. 1.’ 및 사용지역을 ‘대한민국 전 지역’ 으로 하는 전용사
용권을 2024. 2. 1. 유효하게 설정하였고, 丁은 이를 2024. 2. 1. 특허청에 등록하였다. 丙
은 2021. 2. 1.부터 현재까지 A 상표를 사용하여 타월을 판매하고 있다. 丙의 판매 행위
가 甲 또는 丁의 권리에 대한 침해(상표법 제107조 등)에 해당하는지 여부를 논하십시오.
(6점)

<Comment.>

최근 중요 판례로 찍힌 사문서 위조 판례, 스피도(수건) 판례 및 장우동 판례 기반 문제로 보입니다.
무난한 문제였으나, 문제 1의 여파로 시간이 부족하였을 것으로 보입니다. 판례에 기반한 답안을 작
성하셨으면 무난한 결과를 얻으실 것으로 예상됩니다.

[문제-2] “상표권 무단 이전 문제” (상표법은 이하 ‘法’ 이라 함)

I. 설문(1)의 해결

1. 서론
2. 상표법상 침해와 관련된 벌칙 규정
 - (1) 침해죄 - 法230조
 - (2) 몰수 - 法236조
 - (3) 양벌규정 - 法235조

II. 설문(2)의 해결

1. 문제의 소재
2. 乙의 상표권 이전 행위가 적법한지 여부
 - (1) 法96조 1항 1호 (★)

(2) 判例 [사문서 위조 사건(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023도11044 판결)]

상표권이 양수인에게 이전되기 위해서는 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 있어야 한다. 한편 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자를 처벌하도록 규정하고 있는바, 상표권자 이외의 제3자는 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되고, 이를 위반하는 행위는 상표권의 침해행위에 해당한다.

(3) 소결

이전의 합의가 없었으므로 이전 부적법. 따라서, 乙이 상표를 사용하는 경우 고의에 의한 침해에 해당함. 이하 각 행위 검토함

3. 일반 수요자에게 판매

法2조 1항 11호 가목 및 나목에 따른 상표 사용행위이므로 침해죄 성립.

4. 사은품 제공

(1) 判例 (★)

“ ‘상품’ 은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미하는데, 그 중 일부가 사은품 또는 관촉물로서 무상으로 제공되었더라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 상품성을 부정할 것은 아니다.” 라고 판시한 바 있음.

(2) 소결

일부가 유상으로 제공된 이상 제양도 가능성 배제할 수 없음. 乙이 사은품으로 제공하였다고 하더라도 대법원 判例에 따를 때 상품성을 부정할 수 없으므로, 상표를 사용한 것이고 침해죄 성립.

5. 판매목적 소지

(1) 法108조 1항 4호

(2) 소결(결론 오픈)

논란의 소지가 있으나, 간접침해의 경우 침해죄에 해당하지 않는 다고 보는 것이 타당함.

Ⅲ. 설문(3)의 해결

1. 法100조 1항 1호

2. 判例 - 法100조 1항의 ‘제3자’의 의미 (★)

전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록 상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.

3. 설문의 해결

(1) 甲권리에 대한 판단

甲과는 여전히 유효한 통상사용권 계약이 존재하므로 甲의 권리에 대하여는 침해가 아님.

(2) 丁권리에 대한 판단

丁은 등록된 전용사용권자로 양립할 수 없는 제3자임. 丁의 전용사용권에 대하여는 침해에 해당.

甲은 2022. 11. 1 ‘HOLA’ 라는 상표(이하 ‘이 사건 출원상표’ 라고 함)를 ‘의류’ 를 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하였는데, 이 사건 출원상표는 甲의 상표등록 출원일 전에 먼저 출원되어 등록된 乙의 선등록상표(상표: ‘HOLO’, 지정상품: ‘의류’)와 비교하여 표장의 외관 및 칭호가 유사하고, 지정상품이 동일하여 상표법 제34조제1항제7호에 해당된다는 이유로 2023. 11. 10. 특허청에서 거절결정되었다.

甲은 이러한 특허청의 거절결정에 불복하여 2023. 11. 17. 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원에서는 특허청의 원 거절결정과 동일한 이유로 甲의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 2024. 3. 14. 甲에게 심결등본을 송달하였다.

(1) 甲은 乙의 선등록상표에 대해서 조사를 진행한 결과, 乙은 선등록상표에 대해 오래 전부터 국내에서 상당한 정도로 광고선전을 해 오면서 그 지정상품인 ‘의류’ 를 판매해 왔고, 그 결과 乙의 선등록상표는 국내의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 저명한 상표라는 사실을 알아내었다. 반면에 甲의 이 사건 출원상표는 국내의 수요자 간에 널리 인식되어 있는 상표라고 볼 근거가 없는 상황이다. 이러한 사실을 기반으로 甲은 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당되는 상표가 아님을 주장하면서 특허심판원의 심결을 취소해 달라는 취지의 심결취소소송을 특허법원에 제기하고자 한다. 이 경우 甲의 주장을 뒷받침할 수 있는 적절한 청구이유를 판례에 의거하여 설명하시오. (15점)

(2) 甲은 2024. 3. 20. 특허법원에 특허심판원의 심결을 취소해 달라는 취지의 심결취소소송을 제기하였고, 소송 계속 중 甲은 2024. 4. 3. 특허청에 이 사건의 출원상표의 상표등록출원을 취하하기 위한 취하서를 제출하였으며, 해당 취하서는 2024. 4. 5. 특허청에서 수리되어 결국 이 사건 출원상표에 대한 상표등록출원은 취하가 완료되었다. 이 경우 심결취소소송은 어떻게 처리 되는지 판례에 의거하여 설명하시오. (6점)

(3) 甲은 이 사건 출원상표에 대한 상표등록출원을 취하한 후 2024. 5. 7. ‘HOLA’ 라는 상표(이하 ‘이 사건 재출원상표’ 라고 함)를 ‘의류’ 를 지정상품으로 하여 특허청에 다시 상표등록출원을 하면서, 이와 동시에 상표법 제34조제1항제7호에 따른 거절이유가 통지되는 것을 피하기 위해 乙로부터 이 사건 재출원상표의 등록에 동의한다는 내용의 공존동의서를 받아 출원서와 함께 특허청에 제출하였고, 그 결과 이 사건 재출원상표는 별다른 거절이유의 통지 없이 2025. 5. 9. 최종 상표등록이 완료되었다. 그 이후 乙은 2025. 6. 13. ‘HOLA’ 와 유사한 상표인 ‘HOLAR’ 라는 상표(이하 ‘후출원상표’ 라고 함)를 ‘의류’ 와 유사한 지정상품인 ‘티셔츠’ 를 지정상품으로 하여 특허청에 상표등록출원을 하였다. 이 때 乙이 이 사건 재출원상표에 대해 공존동의를 해 준 상황임을 고려하였을 때, 乙의 후출원상표도 상표 등록을 받을 수 있을지 여부를 논하시오. (9점)

<Comment.>

대법원 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결(풀로 판례) 기반인 것으로 보이나, 법리는 룰렉스 判例(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결과 다를바가 없으므로, 포섭이 판가름을 가르는 문제입니다.

[문제-3] “HOLO 문제” (상표법은 이하 ‘法’ 이라 함)

I. 설문(1)의 해결

1. 문제의 소재
2. 法34조 1항 7호의 의의, 취지 및 요건
3. 甲의 주장을 뒷받침할 수 있는 청구이유

(1) 상표 비유사 주장과 관련된 판례

1) 전체관찰의 원칙 (★)

2) 문자상표의 경우의 판례

3) 구체적 출처 혼동이 없는 경우의 판례 (★)

비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다.

(2) 소결

1) 호칭의 비유사 (★)

2) 구체적 출처 혼동 판단 (★)

① 선등록상표(HOLO)의 주지 저명성

이미, 선등록상표는 저명한 상표이고, 국내에서 상당한 광고, 선전을 하였으므로 乙의 출처로 수요자들이 인식할 것임이 명백함.

② 상품의 속성

甲과 乙의 상품 모두 ‘의류’로 동일하기는 하나, 乙이 국내에서 상당한 광고, 선전을 하였으므로 乙의 출처로 수요자들이 인식할 것임이 명백함.

③ 고객층의 성격

국내에서 이미 널리알려진 상황이라면 乙의 고객층은 이미 확고할 것임에 반하여, 甲의 고객층은 전무한 상황으로 고객층의 성격도 상이함.

④ 거래실정

‘의류’는 보통 상표를 중요하게 생각하고 거래하는 상품임. 乙이 국내에서 상당한 광고, 선전을 하였으므로 乙의 출처로 수요자들이 인식할 것임이 명백하므로 출처 혼동의 염려는 없음.

4. 설문의 해결 - 청구이유 요약

- 1) 우선적으로 전체관찰에 의하더라도 호칭 비유사함을 주장
- 2) 당해 상품에 대해 일반적인 거래실정 고려하면 더욱 출처혼동의 염려기 없음을 주장

II. 설문(2)의 해결

1. 소의 이익의 개념

2. 判例의 태도 (★)

상표등록의 출원이 취하된 경우에는 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 비록 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 심결의 취소를 구할 이익이 없고 심결취소의 소는 부적법하게 된다.(대법원 2016. 8. 18. 선고 2015후789 판결.)

3. 설문의 해결

소의 이익 흠결로 소각하.

III. 설문(3)의 해결

1. 문제의 소재

2. 공존동의제도의 의의 및 취지

3. 설문의 해결 - 乙의 후출원 상표의 등록가부

(1) 공존동의관련 심사기준 (★)

공존동을 통해 후출원상표가 등록된 이후 선등록(출원) 상표권자가 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 등록받고자 할 경우에는 후출원상표권자의 동의가 필요하다.

(2) 소결

法34조 1항 7호에 따라 등록 불가

(3) 보론 - 등록강구 방안

공존동의 제도는 法34조 1항 7호 및 선출원주의의 거절이유가 존재하는 경우에만 활용할 수 있는 것인데, 설문(1)에서 乙의 선등록상표가 저명함이 인정된 이상 甲의 재출원상표에는 法34조 1항 11호 또는 12호의 무효사유가 존재함. 따라서, 乙은 甲의 재출원상표에 대하여 法34조 1항 11호 및 12호를 무효사유로 하여 무효심판을 청구하고 후출원상표의 등록을 도모할 수 있을 것임.

甲은 ‘TONY’ 라는 상표가 부착된 ‘텔레비전’ 을 제조 및 판매하는 업을 영위하고 있는 자로서 甲의 ‘TONY’ 상표는 ‘텔레비전’ 과 관련해서 국내에서 널리 알려진 상표이다. 또한 甲은 ‘TONY’ 라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’ 라고 함)를 ‘리모콘(텔레비전을 제어하기 위한 원격조정기를 의미함)’ 을 지정상품으로 하여 상표등록을 취득한 상표권자이다.

乙은 ‘리모콘’ 을 제조 및 판매하는 업을 영위하는 자로서 乙이 제조 및 판매하는 ‘리모콘’ 의 내부 부품에는 ‘TONY’ 라는 문구가 표시되어 있고, ‘리모콘’ 의 외부 하단표면에는 ‘TONY용 텔레비전 전용 만능 리모콘’ 이라는 문구가 표시되어 있다. 이때 乙이 제조 및 판매하는 ‘리모콘’ 의 내부 부품은 일반소비자들이 평상시에는 확인이 불가능한 부품으로서 해당 ‘리모콘’ 을 분해해야만 확인할 수 있는 부품이고, ‘리모콘’ 의 외부 하단표면은 ‘리모콘’ 의 분해 없이도 누구나 쉽게 육안으로 확인할 수 있는 부분이다.

(1) 乙의 ‘리모콘’ 의 제조 및 판매 행위가 이 사건 등록상표에 대한 침해를 구성하는지 여부를 논하시오. (13점)

(2) 甲은 乙의 ‘리모콘’ 제조 및 판매 행위가 이 사건 등록상표를 침해하는 것으로 판단하여 乙에게 상표권 침해 금지를 요구하는 경고장을 발송하였다. 이에 대응하여 乙은 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였고, 해당 무효심판 계속 중에 심판장이 심판사건의 합리적인 해결이 필요하다고 판단하여 甲과 乙의 동의를 받아 본 사건을 산업재산권분쟁조정위원회에 회부하는 결정을 내렸고, 이러한 결정에 따라 본 무효심판은 절차가 중지되고, 산업재산권분쟁조정위원회가 개최되었다. 만약 산업재산권분쟁조정위원회를 통해 甲과 乙간의 원만한 합의가 이루어져 조정이 성립할 경우 본 무효심판은 어떻게 진행되는지 설명하고, 반대로 조정이 불성립할 경우 본 무효심판은 어떻게 진행되는지 설명하시오. (3점)

(3) 물음 (2)에 따른 산업재산권분쟁조정위원회의 개최를 통해 甲과 乙간의 조정이 성립하여 甲이 乙에게 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정해 주었고, 해당 통상사용권의 설정과 관련된 사항은 특허청에 등록 완료되었다. 그 이후 乙은 사업 자금이 필요하여 A 은행으로부터 사업 자금을 대출받고, 대출 채권의 담보를 위해 甲의 동의를 받아 A 은행에 대해 당해 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정해 주었다. 이때 당해 통상사용권을 목적으로 하는 질권의 설정과 관련된 사항에 대해서는 특허청에 등록되지 않았다. 그 이후 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권은 乙에서 丙에게 정당하게 이전되었고, 이러한 통상사용권의 이전과 관련된 사항이 특허청에 등록 완료되었다고 하였을 때, 향후 A 은행이 乙에 대한 대출 채권 회수를 위해 당해 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 행사하는 것이 가능한지 설명하시오. (4점)

<Comment.>

역시나 문제 4는 무난한 논점입니다. 다만, 주된 판례가 아닌 설문(2) 및 (3)은 1차형 O/X 문제로 조문을 찾으시는데 애를 먹으셨을 것 같습니다. 시간 배분이 관건인 문제였을 것으로 보입니다.

[문제-4] “TONY 문제” (상표법은 이하 ‘法’ 이라 함)

I. 설문(1)의 해결

1. 침해의 성립요건 및 문제의 소재

2. 乙의 행위가 상표적 사용에 해당하는지 여부

(1) 상표 사용 중 표시행위의 개념(法2조 1항 11호 가목)

(2) 判例(2005도1637판결, 소니判例) (★)

1) 상표 사용 판단의 원칙(상대주의)

2) 내부부품의 경우

공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유행행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다.

3) 설명적 문구의 경우

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없다.

(3) 소결

1) 내부 부품의 표시

상표의 사용이므로 침해 아님.

2) 설명적 문구

상표의 사용이 아니므로 침해 아님.

II. 설문(2)의 해결

1. 法151조의 2 (★)

(1) 法151조의 1 제1항 - 조정위원회 회부

심판장은 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 산업재산권분쟁조정위원회에 회부할 수 있다.

(2) 法151조의 2 제3항 - 조정절차 결과의 효과

심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 심판절차의 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판청구는 취하된 것으로 본다.

2. 설문의 해결

(1) 조정이 성립한 경우

무효심판은 취하되고, 처음부터 없었던 것으로 봄.

(2) 조정이 불성립한 경우

무효심판은 재개되고 계속하여 심리하게 됨.

Ⅲ. 설문(3)의 해결

1. 사용권 및 질권 설정등록의 효력

(1) 사용권 설정등록의 효력

전용사용권 또는 통상사용권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(法100①1).

(2) 사용권을 목적으로 하는 질권 설정등록의 효력 (★)

전용사용권 또는 통상사용권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(法100①2).

2. 설문의 해결

통상사용권을 정당하게 이전받고 먼저 설정등록을 마친 丙은 질권설정과 관련하여 양립할 수 없는 제3자에 해당함. 따라서, A은행은 질권행사 불가함.